

1502994-02.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... de turnos] indicam dedicação à atividade criminosa de tráfico de drogas.

Não pode ser desprezado o histórico infracional, pois o denunciado ostenta passagens recentes pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas em outubro/2020 [processo n. 1503196-47.2020] e junho/2021 [1502149-04.2021], tendo sido desinternado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502994-02.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502994-02.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO HENRIQUE SALES BRANDÃO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra LUCIANO HENRIQUE SALES BRANDÃO, tendo-o por incurso no art. 33, "caput", da Lei 11343/06 do Código Penal, imputando-lhe os seguintes fatos: no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 18h, na Rua Santa Teresinha, Vila São José, Área Rural, nesta cidade e comarca de Cubatão, LUCIANO HENRIQUE SALES BRANDÃO, qualificado às fls. 13/14, em concurso e unidade de designios com indivíduo não identificado, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 69 (sessenta e nove) porções de cannabis sativa, substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 0,8 gramas, 233 (duzentos e trinta e três) porções de cocaína, pesando aproximadamente 350 gramas, bem como 63 (sessenta e três) porções de "crack", pesando aproximadamente 0,35 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 07 e laudo de constatação preliminar de fls. 10).

O réu foi notificado e citado [fls. 141] e, por intermédio de defensor nomeado, apresentou defesa prévia [fls. 89/98].

Recebida a denúncia [fls. 144/145], foi designada audiência, na qual foram colhidos os depoimentos de testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu, com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a

materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnano pela sua condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, sustentando não existir prova suficiente para a condenação [CPP, art. 386, VII] e, em caso de condenação, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fls. 01/02], pelo boletim de ocorrência [fls. 03/05], pelo auto de apreensão e exibição [fls. 07], pelo auto de constatação preliminar [fls. 08/09], pelo laudo definitivo químico-toxicológico [fls. 161/163] e pela prova oral sob o crivo do contraditório. A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelo depoimento de testemunhas.

Israel Gomes dos Santos, policial civil, testemunha, disse ter integrado diligência policial em viatura descaracterizada, distando do local em que estava o réu menos de 100 metros. Percebeu aproximação de terceiro, aparentemente usuário, quem conversou com o acusado e outro indivíduo, de moletom e capuz preto, que o acompanhava, quem retirou algo de um saco preto e o entregou para esse aparente usuário. Em seguida, o terceiro indivíduo, traficante, entregou algo para o réu, aparentando ser dinheiro. Desembarcaram para realizar a abordagem. O terceiro indivíduo fugiu. O rapaz de capuz preto evadiu-se e seu parceiro correu no seu calção. Abordou o acusado perto de um bar. Na posse do réu apreendeu R\$ 600,00. O réu confirmou que era o “dono do horário “da venda de entorpecentes naquele momento. Disse que o dinheiro apreendido “era do movimento do tráfico”. O segundo indivíduo conseguiu se evadir, deixando uma sacola com as drogas no chão.

Em igual sentido o depoimento de Nivaldo Herondino Borges, policial civil.

Ratificou ter perseguido o sujeito “de capuz preto”, sem êxito, quem tentou jogar a sacola sobre telhado, caindo na calçada.

Gabriel Mesaque dos Santos Silva, testemunha, disse que estava no seu local de trabalho no momento do acontecimento. O réu estava nas suas costas quando todo mundo saiu do bar. O acusado foi o último a sair do bar e estava junto com a mulher dele que mora próximo. Todas as pessoas presentes foram abordadas. Não foi abordado porque estava trabalhando. Foi a mãe do acusado que o procurou para depor. O acusado havia ingerido bebida alcoólica e na sua concepção estava bêbado. Não tem conhecimento da venda de drogas pelo acusado e no local. Nunca presenciou tráfico no bar. Não presenciou a apreensão de drogas com o réu. Sabe da apreensão de dinheiro com ele. Não viu desrespeito ou resistência por parte do acusado em relação aos policiais. O réu pagou seu consumo em dinheiro. Ele estava com notas de R\$ 100,00. No seu bar ele pagou R\$ 75,00. Tem difícil acesso a visualização da rua, mas como a abordagem foi bem em frente ao seu bar conseguiu. O réu estava acompanhado de sua mulher, quem ignora o nome. Junto com o réu saíram outros quatro rapazes, os quais também foram abordados. Não viu a polícia apreendendo drogas, pois estava dentro do bar. Viu três policiais, dois homens e uma mulher. A viatura parou na frente do bar. Trabalha no local há oito meses e não viu prática de tráfico no local nesse período.

Interrogado em juízo o réu negou os fatos. Estava acompanhado de sua mulher no local consumindo bebida alcoólica. Trabalhava como atendente na adega 013, do senhor Rodrigo, localizada na Vila Esperança. Não sabe o telefone do seu chefe de memória. Recebia por mês R\$ 800,00. Foi preso com a quantia de R\$ 600,00. Recebe também uma pensão do seu pai, em torno de R\$ 1.000,00. Antes do bar estava com R\$ 700,00. Recebeu R\$ 200,00 reais da sua mãe e o restante ficou com sua mãe. Recebeu uma parte do dinheiro do seu trabalho via Pix e uma em mão. O dinheiro é depositado na conta da sua esposa, sempre no dia 25. Já foi abordado pelos policiais que realizaram sua prisão anteriormente, mas não sabe se eles possuem alguma coisa contra vocês. Gabriel foi quem o atendeu no bar. Do interior do bar não dá para ter

uma visão ampla da via pública, mas estava próximo a porta do bar. Foi abordado com outras quatro pessoas. Não as conhece, somente de vista. São falsas as afirmações feitas pelos policiais em juízo. Estava extremamente alcoolizado no momento da abordagem.

Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

Interrogado em Juízo, o réu negou a veracidade da imputação.

A negativa inconsistente não infirma a versão das testemunhas, tornando imperiosa a responsabilidade criminal do réu.

É seguro e harmônico depoimento dos policiais civis com todo o contexto probatório, corroborando em juízo a dinâmica dos fatos constante da denúncia.

Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. Aliás, os atos funcionais do servidor público são presumidos verdadeiros [CF, art. 37].

Assim, não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, “[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência”. Por oportuno, confira-se: “Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública”.

A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria e prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.

No mais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal.

O depoimento de Gabriel não é incompatível com a versão dos policiais, pois afirmou que o réu estava no local com sua mulher consumindo. Não viu prática de tráfico algum por ninguém, incluindo a pessoa “de capuz preto”. Destacou, ainda, que do interior do bar não tinha visualização externa.

Os policiais, por sua vez, descreveram conduta do réu de partícipe de traficante, porque dele recebia o numerário ilícito.

E, ainda, em desfavor do depoimento de Gabriel, há o depoimento dos policiais e efetiva apreensão de entorpecentes. Por fim, eram várias pessoas, mas o réu foi recolhido preso, a corroborar a verossimilhança de anterior visualização policial. Afora isso, a alternativa restante é odiosa incriminação de inocente por agentes estatais. E os policiais descreveram dinâmica fática segundo a qual o réu, na companhia de outro que mantinha o depósito de entorpecentes em sacola, igualmente conversou com usuário, de modo que inarredável consciência e vontade de aderir à

conduta e aproveitar-se do resultado ilícito. Houve tentativa de fuga quando da abordagem policial.

Assim, não se trata de simples imputação da conduta de ter sido flagrado com numerário, o qual, aliás, não foi comprovada a origem, embora narrada dinâmica circunstanciada de pagamento e modo de recebimento em seu interrogatório. Aliás, nem mesmo o empregador foi comprovado, ressaltando narrativa diversa no interrogatório policial [fls. 13].

Logo, a negativa do réu está isolada nos autos, não tendo carreado aos autos qualquer indício de sua alegação de mera passagem pelo local. Nesse sentido, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o alibi apresentado." [STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 4.376/SP, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.1.2005].

Desse modo, o fato alegado pelo réu, sem repercussão em elemento de prova objetivo ou subjetivo, não gera dúvida objetiva razoável em seu favor.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: [a] a quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes; [b] a narrativa dos policiais civis; [c] a apreensão de dinheiro no contexto fático.

Inviável, pois, acolher-se a pretensão absolutória ou desclassificatória, ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuária não exclui a de traficante. Registre-se que para configuração do crime imputado ao réu não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito. Assim, pois, é de se reconhecer que o réu trazia consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006, mediante a norma de extensão do art. 29 do Código Penal.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Evitando-se bis in idem, a reprovabilidade da natureza, diversidade e quantidade da substância entorpecente apreendida será objeto de exame na terceira fase.

Assim sendo, nos termos do art. 59 do Código Penal, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, a pena base deve ser fixada no mínimo legal.

Em segunda fase, fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n.º 231, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

Para a incidência da causa minorante é de rigor a concorrência dos requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração à organização criminosa.

O art. 33, §4º, prevê uma causa especial de diminuição da pena de 1/6 a 2/3 e que incide somente no art. 33 caput e §1º presentes os requisitos legais.

O legislador, ao prever a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, almejou conferir tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, reduzindo a reprovabilidade de sua conduta prejudicial à saúde pública.

Para a incidência da causa minorante, no entanto, de rigor a concorrência dos requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas, tampouco integração de organização criminosa.

A conduta de dedicar-se a atividades criminosas pode ser inferida das circunstâncias objetivas que permeiam o crime e subjetivas quanto à pessoa do agente, que tornem evidente, acima da dúvida razoável, a incursão do traficante não

reincidente e que não ostente maus antecedentes na atividade criminosa com habitualidade.

Assim sendo, a dedicação às atividades criminosas pode decorrer da conduta social desajustada do réu, concurso eventual de pessoas, receptação, petrechos relacionados ao tráfico e exame da quantidade, variedade e nocividade da droga. Com efeito, "A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." [SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129].

Nenhuma atividade lícita foi comprovada nos autos.

Nesse contexto, em especial no caso, a quantidade expressiva, a variedade e nocividade da droga, por demonstrar destacável potencial de lesividade à saúde pública, podem igualmente autorizar conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas.

Assim sendo, a variedade e a quantidade de entorpecente, bem como a organização do exercício da mercancia ilícita [policiais reportaram confissão extrajudicial de turnos] indicam dedicação à atividade criminosa de tráfico de drogas.

Não pode ser desprezado o histórico infracional, pois o denunciado ostenta passagens recentes pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas em outubro/2020 [processo n. 1503196-47.2020] e junho/2021 [1502149-04.2021], tendo sido desinternado aos 12/01/2022 [fls. 26; Processo n. 0006412-88.2021]. O presente fato data de 29 de agosto de 2022.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, para fins de consolidação jurisprudencial, firmou orientação no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

Sabido que o indício é o fato conhecido e secundário conducente, por indução lógica, à existência de outro fato, que pode ser considerado causa ou efeito daquele, segundo o livre convencimento motivado do julgador, considerando o que ordinariamente acontece (experiência), na forma do art. 239 do Código de Processo Penal.

Pois bem, o indício (indução lógica) pode autorizar presunção (dedução lógica), sendo certo que tanto aquele quanto esta, ou esta mediante aquele, autorizam o reconhecimento de um fato prejudicial ao agente, se suficiente o bastante o juízo de probabilidade nos limites da certeza jurídica para prevalecer sobre o princípio do in dubio pro reu.

Ora, a expressiva quantidade da droga apreendida e a ausência de apontamento de fonte lícita de numerário suficiente para sua aquisição são circunstâncias que autorizam a presunção de dedicação a atividade criminosa, bem como pressupõe integração a organização criminosa.

A propósito, o E. Supremo Tribunal Federal já ressaltou que "[a] criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva". [STF – HC n. 111.666, rel. Min. Luiz Fux, j. 8.5.2012].

Assim, pois, a pena definitiva é de 5 [cinco] anos de reclusão com 500 [quinhentos] dias-multa.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49; Lei n. 11.343/06, art. 43], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea b, c/c § 3º do Código Penal.

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese, por ausência do requisito objetivo.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [CP, art. 44, caput] e a suspensão condicional da pena [CP, art. 77, caput], especialmente à vista da vedação prevista no do art. 44, caput, da Lei 11.343/06 [cf. RESp n. 1358147, rel. Min. Marilza Maynard, j. 18.4.2013].

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO LUCIANO HENRIQUE SALES BRANDÃO, qualificado anteriormente, às penas de 5 [cinco] anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, com 500 [quinhentos] dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Dê-se à droga apreendida a destinação prevista no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, preservada quantidade para eventual contraprova.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus commissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do Código de Processo Penal] pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a dinâmica desenvolvida para o exercício da traficância, é de ser mantida prisão cautelar, mormente considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, para, ao final, ser condenado à prática de crime equiparado a hediondo, cujo cumprimento se iniciará no regime fechado e estava traficando droga altamente viciante em concurso de agentes [cocaína e crack], cujos efeitos deletérios são por todos conhecidos, tudo a revelar que a liberdade do réu colocará em risco a ordem pública [CPP, art. 312], revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa [CPP, art. 282, §6º]. Por fim, observo que, diante da prova no sentido de que o réu estava realizando a mercancia da droga, resta indiscutível que os bens apreendidos eram utilizados para a prática do tráfico ou dele oriundo [o dinheiro]. Nessa situação, imperioso o perdimento.

Inaplicável à hipótese a fixação do valor mínimo para reparação de danos [CPP, art. 387, IV] por se tratar de crime vago.

Após o trânsito em julgado: [a] expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; [b] notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de dez dias, nos termos do art. 50, caput, do Código Penal [TJSP, Provimento CG n. 11/2015]; [c] oficie-se o TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF; [d] oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais. Fixo os honorários advocatícios das patronas dos réus, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso e expedindo-se as competentes certidões.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim e se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, RESp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P. I. C.

Cubatão, 17 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA